Autos: 0800218-90.2022.8.12.0041
Ação: Procedimento Comum Cível - Não padronizado
Autor:Maria Izabel Candido
Réu: Município de Ribas do Rio Pardo e outro

Vistos etc.

I - Relatório

Trata-se de ação sob o procedimento comum ordinário ajuizada por **Maria Izabel Candido** em face de Município de Ribas do Rio Pardo e do Estado de Mato Grosso do Sul, pela qual pretende a condenação dos réus ao fornecimento do medicamento SPIRIVA RESPIMAT 2,5mcg, por ser portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) – CID J440.

Relatou que já fez uso de diversos medicamentos previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas da Rede Pública de Saúde, contudo, sem resultado satisfatório, o que comprova a ineficácia dos tratamentos padronizados pelo SUS.

Narrou que buscou todos os órgãos de saúde para a concessão gratuita do tratamento, porém não obteve êxito. Afirmou que é pessoa humilde, aufere baixa renda mensal, o que torna impossível o custeio do tratamento sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela a fim de compelir os requeridos ao fornecimento do medicamento retro mencionado.

Juntou documentos (p. 14-34).

Anexou-se parecer técnico emitido pelo NAT-JUS (p. 37-48).

Deferiu-se a assistência judiciária gratuita e indeferiu-se o pedido de antecipação de tutela (p. 84-86).

Citado (p. 88-89), o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação (p. 95-110). Arguiu preliminar de incompetência absoluta do Juízo Estadual para processar e julgar causa envolvendo a incorporação de nova tecnologia ou fármaco nas alternativas terapêuticas do SUS. No mérito, defendeu que a parte autora não comprovou a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS, a necessidade específica do fármaco postulado e que não há comprovação do preenchimento dos três requisitos cumulativos estabelecidos na tese vinculante do STJ (tema 106). Argumentou que a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

CONITEC já promoveu a análise para incorporação do(s) medicamento(s) Brometo de tiotrópio por meio do Relatório de Recomendação nº 68, tendo deliberado, por unanimidade de seus membros, por recomendar a sua não incorporação. Como justificativas, os técnicos da CONITEC expuseram, com base na análise de evidências científicas de alta qualidade, que até o momento, os estudos não demonstraram benefícios significativos do tiotrópio em relação aos beta2LA ou à associação de beta2LA+CI. Além disso, em alguns estudos, o medicamento aumentou o risco de mortalidade total ou cardiovascular, principalmente quando utilizado com o inalador Respimat®' pois a mesma não reflete os dados clínicos de eficácia e segurança do brometo de tiotrópio publicado na literatura médica especializada". Até o momento, os estudos disponíveis não são suficientes i) para estabelecer definitivamente os benefícios clínicos do tiotrópio em relação aos beta2LA ou à associação de beta2LA+CI e ii) para demonstrar a segurança especificamente em relação ao Respimat. Subsidiariamente, postulou no caso de procedência a) seja estipulada a obrigatoriedade da apresentação de receita médica atualizada para retirada dos medicamentos e que seja autorizado o fornecimento com base no princípio ativo (art. 3º, §2º da Lei n. 9.787/99); b) não haja condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual (Súmula 421/STJ) ou sejam os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no art. 85, §8º, CPC (equidade) ou não haja condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da vedação contida no caput do art. 55 da Lei n. 9.099/95; c) seja o cumprimento da obrigação direcionado à União e, no caso de custeio pelo Estado, seja garantido o direito ao ressarcimento; d) no caso de execução forçada do julgado, não haja fixação de multa diária, dando-se preferência ao bloqueio de verbas, nos termos do enunciado 74 da Jornada de Direito da Saúde5; e) em caso de bloqueio de valores para aquisição do medicamento, seja observado o PMVG, devendo a nota fiscal ser emitida em nome e CNPJ do Estado.

Citado (p. 114-115), o Município de Ribas do Rio Pardo contestou a ação (p. 124-134). Arguiu preliminar de incompetência absoluta do Juízo Estadual para processar e julgar causa envolvendo a incorporação de nova tecnologia ou fármaco nas alternativas terapêuticas do SUS. No mérito, sustentou que não há nos autos a prova da imprescindibilidade do uso dos medicamentos, tampouco da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS como atestado pelo NAT-JUS. Advogou, ainda, a inadequação da multa cominatória como mecanismo para compelir o Poder Público ao cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, alegou que os honorários sucumbenciais devem ser

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

fixados à razão de 50% a ser arcado por cada ente. Acostou documentos (p. 88-90).

Intimada, a Defensoria Pública ofereceu réplica às contestações (p. 92-118). Juntou documentos (p. 135-138).

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento autuado sob o nº 1407288-38.2022.8.12.0000, o qual restou provido em acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça deste Estado, transitado em julgado (p. 139-165).

Intimadas a especificar provas (p. 183), a parte autora e os requeridos requereram o julgamento antecipado do mérito (p. 187, p. 189 e p. 193).

Este é, em síntese, o relatório. **Passo a decidir.**

II - Fundamentação

1. Das preliminares

1.1. Da preliminar de incompetência

Deveras, importa examinar a competência da Justiça Estadual do processamento e julgamento do feito, uma vez que o fármaco postulado, segundo parecer emitido pelo NAT-JUS (p. 37-38), não está incluído no RENAME 2022.

Com efeito, a partir da interpretação do artigo 196 da Carta Magna, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que "*o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente"* (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Em sede de embargos declaratórios, a Suprema Corte revisou a tese fixada no referido tema com o propósito de delimitar a competência administrativa de cada ente federado dentro do Sistema Único de Saúde e evitar a desestruturação de toda a gestão descentralizada do SUS. No julgamento do aludido recurso, restou fixada nova tese, nos seguintes termos:

> "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." (RE 855178 ED,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

> Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No voto do ilustre redator do acórdão, Ministro Edson Fachin, foi enfatizada a necessidade de observância pelo Juízo da inclusão ou não de determinado ente no polo passivo da demanda em consonância com as diretrizes e as suas atribuições estabelecidas pela Lei nº 8.080/90, inclusive para fins de deslocamento de competência. Confira-se breve excertos do aludido voto com o devido destaque:

> "Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);
> **ii) Afirmar que "o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente" significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;**
> iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
> **iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;**
> **v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;**
> vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.
> [...]
> Em síntese, a RENAME é a relação de medicamentos inserta nas políticas públicas (ou em outras palavras: as dispensadas de forma universal e igualitária, ou, ainda, o que comumente se denomina de medicamentos "padronizados" – dispensados pela rede pública). Ela dispõe sobre a assistência farmacêutica em complemento à assistência terapêutica prevista nas RENASES, que são as relações de ações e serviços de saúde nas mesmas condições dispensados à sociedade.
> Para definir as implicações decorrentes das premissas jurídicas adotadas, no âmbito da solidariedade dos entes estatais (quanto às prestações envolvendo "direito à saúde"), valho-me do exame das espécies de tutela realizado pelo e. Relator da STA

Endereço: Rua Waldemar Francisco da Silva, 1017, Nossa Senhora da Conceição I - CEP 79180-000,
Fone: (67) 3238-1242, Ribas do Rio Pardo-MS - E-mail: rrp-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

175, após a realização de exitosa Audiência Pública:
1ª espécie: pretensão que veicula medicamento, material, procedimento ou tratamento constante nas políticas públicas.
Neste caso, ou seja: quando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material.
[...]
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. unico c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja "garante" de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação.
Nesses casos: em que há um responsável previamente determinado (por lei ou pactuação entre os gestores), mas se impõe a responsabilidade a outro ente federado, que acaba cumprindo a obrigação no lugar do primeiro, é obrigação do magistrado, em face do dever de ressarcimento, reconhecer tal fato (desde, claro, que da relação jurídico-processual tenham participado todos os devedores), para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. É nessa linha, aliás, o Enunciado n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: "A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.x
2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas.
A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3):
"Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.x
<u>Como regra geral, nas três "subespécies" apontadas, a União comporá o polo passivo da lide.</u> Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: · Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja

Endereço: Rua Waldemar Francisco da Silva, 1017, Nossa Senhora da Conceição I - CEP 79180-000,
Fone: (67) 3238-1242, Ribas do Rio Pardo-MS - E-mail: rrp-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

> diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90).
> · Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90, in verbis: [...]
> E embora haja vedação legal à dispensa administrativa pela rede pública, a lei orgânica do SUS não silenciou quanto à definição do responsável pela obrigação, quando esta decorrer de condenação judicial à aquisição e à dispensa de medicamentos, procedimentos, tratamentos ou produtos experimentais ou de uso não autorizado pela ANVISA: [...]
> **A partir dessa importante alteração na Lei do SUS (posterior ao julgamento na STA 175 e certamente por ele influenciada) há regra expressa de divisão de responsabilidade (pelo financiamento ou custeio) inclusive para prestações de saúde que não constam das políticas públicas, mas que são determinadas judicialmente.**
> [...]
> Por fim, ao se delinearem critérios mais visíveis, efetiva-se, também, segurança e isonomia. As instâncias ordinárias passam a ter maior grau de previsibilidade em relação à sua própria competência, condições melhores de proferir comandos mais exatos, mais diretos, que suscitem menos litigiosidade entre os entes federativos (menos demandas regressivas) e que, nessa ordem de ideias, também resultem, como dito, em provimentos mais eficazes, sob o aspecto da celeridade e da logística, para os cidadãos. [...]"
> (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Não se desconhece que a definição da competência da Justiça Estadual em casos de fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas públicas do SUS ainda permanece em discussão no âmbito do Eg. TJMS. A exemplo dessa divergência jurisprudencial, reproduzem-se ementas dos seguintes julgados das Colendas Câmaras Cíveis do Eg. Tribunal:

> "AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO – LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS (RENAME) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS AÇÕES DE SAÚDE – ESCOLHA PELO AUTOR DO ENTE DEMANDADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a legitimidade da União para o fornecimento de medicamento(s) não padronizado(s) na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) e, por isso, não incorporado(s) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de modo a atrair, assim, para o caso dos autos, a competência da Justiça Federal. 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Precedentes do STJ. 3. Nesse sentido, a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), relaciona-se ao Cumprimento De Sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não podendo importar na conclusão no sentido de eventual competência exclusiva da União, ou de outro ente público, pois isso implicaria afastar o caráter solidário da obrigação, que foi ratificado no precedente qualificado da Suprema Corte. Precedentes do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido."
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000745-04.2021.8.12.0000, Ponta Porã, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 16/12/2021, p: 10/01/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS ESTADUAL E MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – APLICABILIDADE DO DETERMINADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178/SE, PELO STF, COM FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL – OUTROS JULGADOS DO STF QUE CORROBORAM O DECIDIDO NO RECURSO PARADIGMA – NA HIPÓTESE DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE NA RENAME PARA O CASO DA AUTORA, A UNIÃO DEVE NECESSARIAMENTE COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. 1) Havendo requerimento de medicamento que não está padronizado pelo SUS, ou seja, não constante na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), é o caso de imprescindível inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade do Ministério da Saúde, com o auxílio do CONITEC, de inclusão de novos medicamentos e terapêuticas destinadas ao tratamento das doenças dos pacientes atendidos pelo SUS. 2) Determinação que atende ao comando do decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793/STF), em que houve, pelo STF, fixação de tese de Repercussão Geral, cuja observância pelos demais órgão do Poder Judiciário é obrigatória. Outros precedentes do STF que, interpretando o contido no julgado paradigma, corroboram a conclusão acima apontada. 3) A inclusão da União no polo passivo da demanda atrai automaticamente a competência da Justiça Federal para julgamento do feito, pelo que se impõe a remessa dos autos para a referida Justiça Especializada. 4) Preliminar de Incompetência acolhida."
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000597-90.2021.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 06/12/2021, p: 10/12/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E NÃO PADRONIZADOS PELO SUS – MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA RENAME – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 793) – REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO. I. Em que pese ainda esteja vigorando a tese de responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde, fato é que a partir de agora deve-se passar a observar os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada pessoa jurídica de direito público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). II. Em razão da pretensão veicular pedido de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, a União deve integrar necessariamente o polo passivo da demanda, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporar novo medicamento, produto e procedimento na RENAME, nas diretrizes terapêuticas ou protocolos clínicos, o que é integralmente ligado ao respectivo ente público. III. Deve ser dado provimento ao recurso para reconhecer que, conforme o Tema n. 793 do STF, a responsabilidade do ente federado para o fornecimento dos medicamentos pleiteados é da União, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. IV. Recurso provido."
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000744-19.2021.8.12.0000, Camapuã, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 30/11/2021, p: 07/12/2021)

Ocorre que, compulsando o acervo jurisprudencial do Supremo

Endereço: Rua Waldemar Francisco da Silva, 1017, Nossa Senhora da Conceição I - CEP 79180-000,
Fone: (67) 3238-1242, Ribas do Rio Pardo-MS - E-mail: rrp-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

Tribunal Federal, identifique-se que a Suprema Corte, em recente decisão monocrática, datada de 15/12/2021, proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes enfrentou o tema ora em discussão. Nesse caso, o ilustre Ministro julgou procedente reclamação constitucional proposta pelo Estado de Goiás para cassar o acórdão prolatado pelo Eg. TJGO à vista da insistência daquela Corte em manter excluída a União no polo passivo da demanda, ainda que o fármaco postulado pela parte não estivesse incluído na RENAME, o que implicava ofensa ao precedente firmado no Tema nº 793/STF. Pela pertinência, transcreve-se o seguinte excerto:

> "Consoante consta dos autos, em 26.4.2021, julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que contrariava o entendimento firmado por esta Corte no Tema 793-RG, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (eDOC 24) Diante disso, o Tribunal reclamado, promovendo novo julgamento do feito, assim decidiu:
> "No que se refere à competência da Justiça Comum Estadual para julgar a presente demanda, saliento que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados (RE nº 855.178/SE – Tema 793 com repercussão geral – DJe 04/06/2019), só podendo ser afastada a competência da Justiça Comum Estadual para julgar demanda prestacional na área da saúde quando o medicamento pleiteado não tiver registro na ANVISA (RE nº 657.718 – Tema 500 com repercussão geral – DJe 31/05/2019) o que não é a hipótese em análise.
> Além disso, em relação à responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
> Nesse cenário, é manifesta a responsabilidade impingida ao Estado de promover medidas capazes de garantir a todo cidadão o efetivo acesso a saúde.
> [...]
> **Logo, em consequência do indubitável direito garantido ao cidadão de receber do Poder Público o tratamento, inclusive medicamentoso, necessário para a manutenção ou recuperação de sua saúde, e da responsabilidade solidária dos entes federados, não há que se falar em ilegitimidade do Estado de Goiás em responder pelo tratamento postulado.**
> **Desta forma, embora haja o reconhecimento da possibilidade de ressarcimento pela União do gasto com o medicamento, nos moldes do tema 793, no caso dos autos, em consonância com o entendimento jurisprudencial não se mostra pertinente integrar a União a lide, conforme pleiteia o Estado de Goiás. (…). Nesse contexto, verifica-se que é de responsabilidade do Estado o fornecimento da medicação pleiteada, podendo utilizar-se da via administrativa para buscar o ressarcimento financeiro da União. Assim, o afastamento das preliminares é medida que se impõe". (eDOC 36)**
> Pois bem
> Na decisão de eDOC 28, julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado no ponto em que contrariou o entendimento firmado por esta Corte no Tema 793-RG, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC.
> Reforço que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no paradigma da repercussão geral (tema 793), o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, no caso de de tratamento padronizado na rede pública, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material.
> Ora, nesse julgamento, o Plenário desta Corte Suprema entendeu por revisar a tese

Endereço: Rua Waldemar Francisco da Silva, 1017, Nossa Senhora da Conceição I - CEP 79180-000,
Fone: (67) 3238-1242, Ribas do Rio Pardo-MS - E-mail: rrp-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

> reafirmada pelo Colegiado Virtual, a qual reconheceu que em demandas de saúde os entes federados podem ser demandados de forma solidária.
> [...]
> **Dessa forma, tratando-se na hipótese vertente de fornecimento de medicamento Voriconazol 200mg, fármaco esse não constante de Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e de nenhuma lista de distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde – SUS (eDOC 2, p. 159), entendo que a autoridade reclamada, ao deixar de incluir a União no polo passivo da demanda, persistiu na ofensa ao tema 793-RG, nos termos combatidos pela decisão de eDOC 28.**
> **Ante o exposto, tendo em vista o desrespeito à decisão proferida nos presentes autos, defiro o pedido de eDOC 36 para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, quando do rejulgamento da demanda, e determinar que outro seja proferido, com observância da jurisprudência desta Corte, incluindo-se necessariamente a União no polo passivo do Mandado de Segurança 5385426.63.2018.8.09.0000."**
> (Rcl 41954 TPI / GO – GOIÁS TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA RECLAMAÇÃO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 15/12/2021 Publicação: 17/12/2021)

Em igual direção, citem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas por outros eminentes Ministros da Suprema Corte, a indicar a sedimentação dessa posição jurisprudencial na esteira dos artigos 927, III, e 932, IV, "b", e V, "b", do CPC:

> (ARE 1301670 / PR – PARANÁ, RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 17/12/2020, Publicação: 07/01/2021)
>
> (RE 1356368 / RS - RIO GRANDE DO SUL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 02/12/2021, Publicação: 11/01/2022;
>
> (RE 1349838 / RS - RIO GRANDE DO SUL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 06/12/2021, Publicação: 07/12/2021)
>
> (RE 1330806 / RS - RIO GRANDE DO SUL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 19/07/2021, Publicação: 21/07/2021)

Com especial destaque, menciona-se a liminar deferida pelo ilustre Ministro Dias Toffoli, no julgamento da reclamação constitucional RCL 50597 MC / MS, oriunda deste Estado, no qual o eminente Ministro enfatizou que "***o juízo reclamado condenou o Estado do Mato Grosso do Sul ao fornecimento de medicamentos que, embora registrados na Anvisa, supostamente não se encontram incorporados ao SUS (Insulina Degludeca 100UI/mL e Liraglutida 6mg/mL), tendo afastado a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que não se atendeu integralmente o que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.***" (grifou-se) Rcl 50597 MC / MS - MATO GROSSO DO SUL,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 30/11/2021, Publicação: 01/12/2021).

Cabe frisar, por fim, recente acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de considerar um litisconsórcio passivo necessário em se tratando de fármaco não incorporado dentro das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS. Eis o teor da ementa do julgado:

> "Reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, inciso LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). Reclamação julgada procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário "direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências". 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3. Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º)."
> (Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)

Nessas condições, revela-se indubitável o interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das causas em que o medicamento pleiteado pela parte demandante não está incluído dentre as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, mais precisamente na RENAME.

Essa situação se reflete no caso em tela, na medida em que, consoante parecer lavrado pelo NAT-Jus, o fármaco em questão não consta na lista pública constante na RENAME, o que conduz à incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento desta demanda.

Todavia, diante do princípio dispositivo e do disposto no artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, revela-se inviável o chamamento de ofício da União para integrar o polo passivo desta ação. Com efeito, o referido dispositivo legal é claro ao atribuir à parte autora o ônus de indicar e promover a inclusão e a citação dos réus a fim de preservar a eficácia de eventual pronunciamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

jurisdicional. Por consectário lógico, impõe-se, previamente a qualquer deliberação sobre a remessa dos autos à Justiça Federal ou a extinção do feito, a intimação da parte autora para promover a emenda à petição inicial, forte no artigo 321 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito os seguintes arestos do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS. Agravo Interno Cível n. 1418963-32.2021.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 29/03/2022, p: 31/03/2022; e Agravo de Instrumento n. 1404881-93.2021.8.12.0000, Ponta Porã, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 07/09/2021, p: 14/09/2021).

Ocorre que, em razão da multiplicidade de processos com idêntica questão de direito aqui discutida, visando sanar a controvérsia existente entre órgãos da Justiça Federal e da Justiça Estadual, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Assunção de Competência - IAC nº 14 e julgou o caso, fixando várias teses em precedente de seguinte ementa:

> "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.
> 1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.
> 2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.
> 3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.
> 4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.
> 5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de

Endereço: Rua Waldemar Francisco da Silva, 1017, Nossa Senhora da Conceição I - CEP 79180-000,
Fone: (67) 3238-1242, Ribas do Rio Pardo-MS - E-mail: rrp-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida.
6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.
8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.
9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF.
10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).
11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.
12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte.
13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.
14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.
15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:
a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;
b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.
c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.
(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Paralelamente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal afetou à sistemática da repercussão geral o RE 1366243 (Tema nº 1234/STF), tendo sido inclusive referendada liminar proferida pelo Eminente Ministro Relator, em acórdão de seguinte ementa:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL."
(RE 1366243 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

"REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. **Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. <u>nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo</u>; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada."**
(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Diante da deliberação do STF, deve-se manter este feito processado pela parte autora neste Juízo sem inclusão da União.

Ante o exposto, **rejeito** a arguição de incompetência.

<u>2. Do mérito</u>

<u>2.1. Do julgamento antecipado do mérito</u>

O artigo 355 do Código de Processo Civil prescreve *"[o] juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

houver necessidade de produção de outras provas; e o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349."

Por outro giro, prescreve o artigo 369 do Código de Processo Civil que *"[a]s partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."*

Interpretando esse dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça assentou que "*[o] Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio" e [...] a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -"* (REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Nada obstante essa concepção incorporada pelo novel diploma legal, prevalece, ainda, no ordenamento jurídico o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, de tal sorte que compete ao magistrado indeferir diligências probatórias inúteis, inócuas ou desnecessárias para o deslinde do feito, a teor do artigo 370 do CPC, e, ao fim e ao cabo, exarar a sua decisão, apontando os elementos probatórios que formaram a sua convicção de maneira fundamentada. Preserva-se, assim, a sua posição como destinatário final das provas.

Entendimento contrário significaria uma violação e uma denegação de vigência dos artigos 6º e 139, II, do Código de Processo Civil que impõem o dever ao magistrado de zelar pela duração razoável do processo.

A este propósito, colaciona-se alguns julgados da Corte Superior:

> "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. FALHA NO ATENDIMENTO EM NOSOCÔMIO MUNICIPAL. SEQUELAS. ARTS. 489, § 1º, E 1022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE PROVA PERICIAL. PLEITO INDEFERIDO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. [...]
> 3. De acordo com a jurisprudência consagrada no Superior Tribunal de Justiça, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC, seja ela testemunhal,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. [...]"
(AgInt no AREsp 1718367/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022)

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO INTERPOSTO PELA ALÍNEA "A". INDICAÇÃO ESPARSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS E EM EXAME DO LAUDO PERICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. [...]
4. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o STJ tem o entendimento de que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973).
5. Desse modo, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. [...]"
(AgInt no AREsp 1928578/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 28/03/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. [...]
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, quando o juiz, na condição de destinatário final da instrução, entende que os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção. 2.1. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no AREsp 1947719/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVASÃO DE HACKER À CONTA DE E-MAIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. AFETAÇÃO APENAS DAS QUESTÕES DE FATO. IMPOSIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE MENSAGENS EXCLUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE BITCOINS. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ASTREINTES. REVISÃO. DESCABIMENTO (SÚMULA 7/STJ). [...]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

> 4. O art. 370, parágrafo único, do CPC/2015 cristaliza os princípios da persuasão racional e da livre admissibilidade da prova, autorizando o juiz a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, a decisão que indefere a prova pericial com fundamento na sua inutilidade para a resolução do litígio está em conformidade com esse dispositivo legal.
> 5. O princípio da concentração da defesa ou da eventualidade impõe ao réu o ônus de impugnar, especificadamente, as alegações de fato formuladas pelo autor, sob pena de serem havidas como verdadeiras (art. 341 do CPC/2015). A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação, todavia, é relativa, não impedindo que o julgador, à luz das provas produzidas no processo, forme livremente a sua convicção, bem como atinge apenas as questões de fato. [...]"
> (REsp 1885201/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Esse sistema se infere igualmente de outros dispositivos específicos de cada meio da prova. Exemplos disso são os artigos 443 e 464, § 1º, do CPC que estabelecem, respectivamente, que "*[o] juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: I - já provados por documento ou confissão da parte; e II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados"* e "*[o] juiz indeferirá a perícia quando: I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III - a verificação for impraticável*".

Essa posição assegurada ao magistrado, todavia, não pode ser confundida com um pretexto para a adoção de um sistema de íntima convicção próprio do Tribunal do Júri travestido de sistema de persuasão racional. Com efeito, desvela-se imperativo que o magistrado não apenas se centre em rebater os elementos probatórios aportados aos autos que favoreçam o seu convencimento; igualmente cabe-lhe apontar com argumentos jurídicos os motivos por que os elementos probatórios que militam em desfavor da sua convicção são inidôneos ou incapazes de ilidir os elementos que alicerçam o seu convencimento.

Em outros termos, o sistema do livre convencimento motivado não pode significar um cheque em branco para que a fundamentação de uma decisão apenas faça menção àquele conjunto de elementos de prova ou partes destes que suportam a versão e a convicção formada pelo Juiz. Incumbe-lhe expor os motivos das suas escolhas e os que o levou a repudiar ou conferir menor grau de relevância probatória a outros elementos que, em princípio, teriam o condão de sustentar entendimento diverso sobre a causa. A propósito, transcreve-se lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

> “Na prática forense, são usuais as sentenças motivadas somente com base nas provas que demonstram a hipótese vencedora. Alguém dirá que isso é normal, pois o juiz,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

> quando motiva, deve justificar a razão pela qual optou pela versão de uma das partes.
> Porém, embora o que ocorra na prática possa parecer lógico, o certo é que o juiz não justifica as suas razões apenas ao aludir às provas produzidas por uma das partes. Para que possa realmente justificar a sua decisão, o magistrado não pode deixar de demonstrar que as eventuais provas produzidas pela parte perdedora não lhe convenceram. [...] Nesse caso, fica ainda mais claro que o juiz não pode tomar em conta apenas parte da prova, uma vez que a função de motivação não é de demonstrar uma escolha, mas sim a de justificar porque foi feita uma determinada escolha.
> Lembre-se do que ocorre com muita frequência em relação às provas testemunhais. Diante dessas, muitas vezes o juiz procura recortar os depoimentos das testemunhas para dar ênfase aos trechos que demonstram a hipótese vencedora. Acontece que o juiz não pode considerar uma parte do depoimento e esquecer a outra, como estivesse justificando a versão do vencedor. Desse modo, o juiz não justifica as suas razões, mas sim simplesmente elege as razões de uma das partes. Por isso, é preciso eliminar a ideia de que justificar a decisão é o mesmo do que lembrar as provas e argumentos que servem ao vencedor."[1]

No caso em liça, este feito comporta julgamento no estado em que se encontra pois os elementos probatórios acostados a estes autos e submetidos ao crivo do contraditório são bastantes para solução segura da lide. Por fim, intimados acerca do interesse em provas, ou as partes pleitearam o julgamento antecipado do mérito ou quedaram-se inerte a consumar a preclusão.

2.2. Do direito ao medicamento

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 106/STJ, fixou a tese de que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, desde que presentes cumulativamente os seguintes requisitos: *(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*" (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; e EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

Pela pertinência, transcreve-se a ementa desse aresto:

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. 2º. Ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 437.

Endereço: Rua Waldemar Francisco da Silva, 1017, Nossa Senhora da Conceição I - CEP 79180-000,
Fone: (67) 3238-1242, Ribas do Rio Pardo-MS - E-mail: rrp-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

> "ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
> 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.
> Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.
> 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
> 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."
> (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018.)

Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 657718, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 500/STF), firmou as teses de que *"I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV - As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União*". Colaciona-se a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

ementa desse julgado:

> "Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: "1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União".
> (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020)

No caso em voga, malgrado não incluído no RENAME, a parte autora comprovou a incapacidade financeira para a aquisição do medicamento devido ao patrocínio da causa pela Defensoria Pública. Ademais, consoante parecer do NAT-JUS, o medicamento postulado está registrado na ANVISA e, ao revés do arguido pelo Estado em contestação, está prescrito para tratamento de patologia indicada na bula aprovada pela ANVISA.

Por outro giro, o laudo médico indica a necessidade do medicamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

em voga (p. 25-29), tendo o médico assistente assentado a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS (p. 26-28):

7.4. Quanto à (s) alternativa (s) do SUS anteriormente elencada (s) que porventura não tenha(m) sido utilizada(s), esclareça tecnicamente porque não foi(ram) prescrita(s) ao(à) paciente:
( ) contraindicação ( )efeitos adversos (X)ineficácia ( )resposta terapêutica insatisfatória
( ) outro motivo: Qual: _____
Justificar: TODAS AS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS PARA TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DPOC JÁ FORAM UTILIZADAS, COM RESPOSTA TERAPEUTICA INSATISFATÓRIA

8.Existe (m) no SUS medicamento (s) que possua(m) a mesma eficácia terapêutica daquele(s) ora prescrito(s)?

( ) Sim (X) Não
Se Sim qual: _____

9. O fármaco indicado na sua prescrição pode ser substituído por alguma alternativa oferecida pelo SUS?
( ) Sim* - Especifique qual(is): _____ (X) Não
Se negativa a resposta:
9.1 Qual(is) a(s) vantagem(ns) do tratamento proposto para o(a) paciente se comparado com o(s) fármaco(s) ou tratamento(s) oferecido(s) pelo SUS para a(s) mesma(s) moléstia(s)?
SPIRIVA É UMA MEDICAÇÃO BRONCODILATADORA DE LONGA AÇÃO EM FORMATO DE SPRAY DA CLASSE DOS ANTICOLINÉRGICOS COM AÇÃO DIFERENTE DOS MEDICAMENTOS BRONCODILATOR B2-AGONISTA E CORTICOIDE INALATÓRIO. ESTÁ MEDICAÇÃO ESTÁ INDICADA PARA PACIENTES QUE PERMANECEM COM EXACERBAÇÕES APESAR DO TRATAMENTO COM FORMOTEROL + BUDESONIDA

Por outro lado, o parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico (p. 37-48) indicou alternativas terapêuticas, para controle da patologia e alertou que a CONITEC rejeitou a incorporação desse fármaco recentemente pela CONITEC:

> O Spiriva Respimat (nome comercial) Brometo de Tiotrópio (princípio ativo) é um agente antimuscarínico específico, de longa duração, comumente denominado de anticolinérgico. O brometo de tiotrópio apresenta afinidade similar aos subtipos de receptores muscarínicos M1 ao M5. Nas vias aéreas, a inibição de receptores M3 promove relaxamento da musculatura lisa. A natureza competitiva e reversível desse antagonismo foi demonstrada em estudos com receptores de origem humana e animal e em preparações de órgãos isolados. Nos estudos não clínicos in vitro e in vivo, os efeitos bronco-protetores foram dose-dependentes e duraram por mais de 24 horas. A longa duração do efeito é provavelmente devido à sua dissociação muito lenta dos receptores M3, apresentando uma meia-vida de dissociação significativamente maior que a observada com o ipratrópio. Por ser um anticolinérgico N-quaternário, o tiotrópio é topicamente broncoseletivo quando administrado por inalação, demonstrando uma margem terapêutica aceitável antes de apresentar efeitos anticolinérgicos sistêmicos. A dissociação dos receptores M2 é mais rápida que dos receptores M3; o que, em estudos funcionais in vitro, levou à seletividade (controlada cineticamente) ao subtipo de receptor M3 em relação ao M2. A elevada potência e lenta dissociação do receptor promovem broncodilatação importante e de longa duração nos pacientes com DPOC e asma. A broncodilatação observada após a inalação de tiotrópio é fundamentalmente um efeito local (nas vias aéreas) e não um efeito sistêmico. Indicações Brometo de Tiotrópio é indicado para o tratamento de manutenção de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica-DPOC (incluindo bronquite crônica e enfisema pulmonar), para o tratamento da dispneia associada, melhora da qualidade de vida e redução das exacerbações. Brometo de Tiotrópio é indicado também como tratamento adicional de manutenção para melhora dos sintomas da asma, qualidade de vida e redução das exacerbações em pacientes a partir de 6 anos de idade com asma moderada tratados com pelo menos corticosteroides inalatórios ou asma grave tratados com corticosteroides inalatórios e agonistas beta-adrenérgicos de longa duração que permaneçam sintomáticos. Reações adversas Podem ocorrer reações adversas relacionadas ao Trato gastrintestinal: secura da boca (mais comum), em geral leve e frequentemente resolvida com a continuidade do tratamento e também constipação. Sistema

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

respiratório: tosse e irritação local, incluindo irritação da garganta (similar a outras terapias inalatórias). Sistema cardiovascular: taquicardia. Além disso, relataram-se, normalmente em pacientes susceptíveis, casos isolados de taquicardia supraventricular e de fibrilação arterial associadas ao uso de tiotrópio. Sistema urinário: dificuldade de urinar e retenção urinária (em homens com fatores de predisposição). Reações alérgicas: reações de hipersensibilidade imediata incluindo casos isolados de angioedema. A maioria das reações adversas mencionadas acima pode ser atribuída às propriedades anticolinérgicas de Spiriva. Podem ocorrer outros efeitos anticolinérgicos como visão embaçada e glaucoma agudo. Assim como ocorre com outras terapias inalatórias, pode ocorrer broncoespasmo paradoxal.

Segundo o estudo Comparative efficacy of inhaled medications (ICS/LABA, LAMA, LAMA/LABA and SAMA) for COPD: a systematic review and network meta-analysis (Aziz MIA, Tan LE, Wu DB, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Oct 9;13:3203-3231). Nossa meta-análise de rede é a primeira a utilizar uma estrutura frequentista para comparar de forma abrangente a eficácia de SAMAs, LAMAs, LAMA/LABAs e ICS/LABAs usando estudos controlados randomizados publicados. Uma estrutura frequentista nos permitiu fazer inferências / comparações estatísticas baseadas em testes de significância usando valores-P. Com relação à função pulmonar, nossos resultados mostraram que os LAMAs, LAMA/LABAs e ICS/LABAs levaram a uma melhora maior no FEV1 comparados a placebo e SAMA em monoterapia. Todos os LAMA/LABAs, exceto o aclidinium/formoterol, foram significativamente melhores do que a monoterapia com LAMA na melhora da função pulmonar. Evidências limitadas também sugerem que LAMA/LABAs levaram a melhorias maiores do que ICS/LABAs. É digno de nota que havia mais evidência disponível para a função pulmonar do que outros resultados relevantes para o paciente. Melhorias no VEF1 têm sido correlacionadas com melhorias na qualidade de vida, como demonstrado em análises anteriores. Um estudo recente de Sion et al (2017) relatou achados similares de que as combinações de LAMA/LABAs foram melhores do que o Tiotrópio sozinho ou placebo.

Nossos resultados não mostraram diferenças clinicamente significativas entre os diferentes LAMAs e LAMA/LABAs dentro de suas classes, para todos os desfechos. Esses resultados foram congruentes com outras meta-análises de rede publicadas que compararam os resultados dentro das classes de drogas. Cope e cols., Karabis e cols., e Ismaila e cols. avaliaram a eficácia comparativa entre os agentes de LAMA por meio de uma estrutura bayesiana e não encontraram diferenças entre eles. Da mesma forma, Schlueter e cols. e Huisman e cols. avaliaram a eficácia comparativa entre LAMA/LABAs usando a abordagem bayesiana e não encontraram diferenças entre todos os agentes. Nossa análise, que emprega uma estrutura frequentista e usa uma rede com opções de tratamento mais abrangentes (SAMA, LAMA, LAMA/LABA e ICS/LABA) para DPOC estável, acrescenta mais confiança a essas descobertas e expande a base de evidências existente.

[...]

O Brometo de Tiotrópio não está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) ou outro ato normativo do SUS, diferente da afirmação do laudo da página 12.

Considerações finais: As meta-análises atualizadas demonstraram benefício clínico favorável à associação LAMA/LABA, com evidência de maior eficácia que os demais tratamentos (LABA; LABA/ICS e placebo), e segurança equivalente. A evidência gerada apresentou, majoritariamente, qualidade muito baixa. Os motivos que rebaixaram a qualidade da evidência foram, principalmente, imprecisão na estimativa de efeito, inconsistência nos resultados obtidos e a presença de alguns estudos com alto risco de viés. A avaliação dos LAMA/LABA foi conduzida a partir da classe terapêutica, e não por cada monocomponente isolado, uma vez que não foram encontradas evidências para cada comparação. Contudo, evidências demonstram não haver diferença entre as diferentes associações de LAMA e LABA. Por esse motivo, a avaliação econômica realizada levou em consideração a classe LABA/LAMA ao invés de cada medicamento isoladamente. O impacto orçamentário, entretanto, considerou diferentes cenários para a incorporação de um dos medicamentos LAMA (glicopirrônio, tiotrópio ou umeclidínio), para ser

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

> associado a um dos LABA (formoterol ou salmeterol) já incorporados no SUS, entendendo que, à luz das evidências, é possível considerar a incorporação da alternativa LAMA/LABA com menor custo para o sistema de saúde, sem prejuízo à eficácia do tratamento. No entanto, o que se vê, pelas simulações realizadas, é que o impacto orçamentário das formulações isoladas é maior que aquele dos dispositivos em dose fixa combinada de LAMA/LABA. Recomendação final da Conitec: Os membros da Conitec presentes na 93ª reunião ordinária, no dia 09 de dezembro de 2020, deliberaram por maioria simples recomendar a incorporação no SUS dos medicamentos brometo de umeclidínio associado a trifenatato de vilanterol em dispositivo único, conforme os critérios estabelecidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas-PCDT, e do brometo de tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol para o tratamento de pacientes com DPOC graves e muito graves (estágio 3 e 4), com alto risco (C e D), e demais critérios definidos no PCDT. Foi levado em consideração as evidências científicas disponíveis, a experiência relatada pelos profissionais de saúde e pacientes na consulta pública e a experiência de utilização dos LAMA/LABA apresentada pelas Secretárias Estaduais de Saúde. Assim, os membros presentes no Plenário da Conitec deliberam por maioria simples por alterar a recomendação inicial sobre o tema. Foi assinado o Registro de Deliberação nº 580/2020.
> Decisão: incorporar o brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, e recomendar a incorporação do brometo de tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol para o tratamento de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica graves e muito graves (estágio 3 e 4), com alto risco (C e D) e demais critérios definidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS., conforme Portaria nº 66, publicada no Diário Oficial da União nº 248, seção 1, página 815, em 29 de dezembro de 2020.

Ressalvado meu posicionamento pessoal no sentido de prestigiar o parecer lavrado pelo NAT-JUS, é inquestionável verificar que, em caso similiar, o Eg. Tribunal de Justiça concedeu o fármaco, em acórdão de seguinte ementa:

> "AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - FORNECIMENTO DE BROMETO DE TIOTRÓPIO - APLICAÇÃO DO TEMA N.º 106 – RESP. 1.657.156-RJ – LAUDO MÉDICO A INDICAR A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO POR SER IMPRESCINDÍVEL E MAIS EFICIENTE, AINDA QUE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE FORNEÇA OUTROS FÁRMACOS – AUTOR HIPOSSUFICIENTE – TRATAMENTO DO SUS JÁ ADOTADO E INEFICIENTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 2000527-05.2023.8.12.0000, Coxim, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 31/07/2023, p: 03/08/2023)"

Portanto, nesse cenário, impõe-se a procedência dos pedidos veiculados nesta demanda.

A responsabilidade recairá de maneira solidária entre o Estado e o Município réus em atenção à orientação sedimentada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça até a deliberação definitiva do Supremo Tribunal Federal.

Registre-se, por fim, que, em caso de não fornecimento direto pelo Município e Estado de Mato Grosso do Sul, deverá a parte autora juntar aos autos ao

Endereço: Rua Waldemar Francisco da Silva, 1017, Nossa Senhora da Conceição I - CEP 79180-000,
Fone: (67) 3238-1242, Ribas do Rio Pardo-MS - E-mail: rrp-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

menos três orçamentos para se deferir o bloqueio de valores necessários para a aquisição do mais barato a ser direcionado à empresa, em observância aos Enunciados CNJ nº 53 a 56, com a devida prestação de contas e indicação da conta bancária da instituição ou empresa privada que fornecerá o medicamento:

> "ENUNCIADO Nº 53 Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED.
> ENUNCIADO Nº 54 Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de continuidade do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante integral.
> ENUNCIADO Nº 55 O levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas periódica.
> ENUNCIADO Nº 56 Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros poderão ser observados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)"

2.3. Da multa coercitiva

A *astreinte* é uma forma de coerção indireta capaz de influir na esfera anímica do obrigado para compeli-lo a cumprir, especificamente, a obrigação que lhe é imposta pelo comando judicial. Em outras palavras, é uma forma de obrigar o destinatário da decisão judicial a permitir que o beneficiado possa usufruir, *in natura*, o direito que lhe é assegurado pelo ordenamento jurídico.

Independentemente de quem irá suportar os encargos do descumprimento da ordem, tal medida coercitiva não sofre qualquer limitação quanto ao seu destinatário. Aliás, é de boa política processual que ela seja utilizada justamente contra aqueles que, diuturnamente, mostram-se renitentes no cumprimento das determinações judiciais.

A multa diária (*astreinte*) não tem a finalidade de indenizar a parte autora, mas de servir como instrumento para assegurar a efetividade da decisão que concede a tutela específica. Se a multa não se mostra eficiente para o desiderato pretendido, torna-se necessário encontrar outra maneira de garantir o cumprimento da ordem judicial.

Esse mecanismo está previsto nos artigos 139, IV, 500, 536, §1º, 537, 806, §1º, e 814 do CPC com o objetivo de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

em consonância com os artigos 4º e 6º do CPC.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento do REsp nº 1.474.665/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a tese da legalidade da aplicação de multa diária, consoante se infere da ementa do julgado abaixo:

> "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.
> DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.
> 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
> 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;
> REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.
> 4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.
> Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.
> 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).
> 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

> Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.
> (REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

Alfim, não prospera a suscitada ilicitude na aplicação desse mecanismo.

III – Dispositivo

Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **rejeito** a preliminar e, confirmando a tutela provisória de natureza antecipada com fundamento na urgência, **julgo procedentes** os pedidos veiculados na petição inicial para condenar solidiariamente os réus ao fornecimento contínuo do medicamento SPIRIVA RESPIMAT 2,5mdg (brometo de tiotrópio) à parte autora conforme prescrição médica e enquanto for necessário seu uso, preferencialmente pelo seu princípio ativo (Denominação Comum Brasileira – art. 3º, XVIII, Lei nº 6.360/76), sob pena de sequestro de verbas públicas de multa diária de R$ 500,00 a ser direcionada ao ente público ou ao agente público responsável.

Intime-se a parte autora sobre os valores depositados para juntar aos autos três orçamentos e os dados bancários para proceder ao pagamento direto à empresa. Deverá ser emitida nota fiscal em nome da parte autora e entregue nestes autos. **Caberá à parte autora propor cumprimento provisório de sentença, onde serão deliberadas esas medidas, tendo em vista o efeito exclusivamente devolutivo de eventual apelação (art. 1.012, §1º, V, do CPC).**

Diante da sucumbência dos réus, deverão arcar com os ônus sucumbenciais.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais adiantadas pela parte autora na proporção de 50% para cada, o que não está abarcado pela isenção legal, nos termos dos artigo 24, inc. I, da Lei Estadual n.º 3779/2009.

Acerca dos honorários advocatícios, verifica-se que a parte autora ingressou com esta demanda via Defensoria Pública que se constitui em órgão integrante do Estado de Mato Grosso do Sul, de modo que se aplica a Súmula nº 421/STJ ("*Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.*" - Súmula n. 421, Corte Especial, julgado em 3/3/2010, DJe de 11/3/2010.), reafirmada no julgamento do Tema nº 433/STJ, sujeito ao rito dos recursos repetitivos e mantido em jurisprudência

Endereço: Rua Waldemar Francisco da Silva, 1017, Nossa Senhora da Conceição I - CEP 79180-000,
Fone: (67) 3238-1242, Ribas do Rio Pardo-MS - E-mail: rrp-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

atual:

> "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
> 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).
> 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
> 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios."
> (REsp n. 1.199.715/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 16/2/2011, DJe de 12/4/2011.)
>
> "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
> 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16.2.2011, firmou não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.
> 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1.546.228/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 27.3.2017).
> 3. Agravo Interno não provido."
> (AgInt no REsp n. 2.020.240/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Ocorre que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.002/STF, sujeito à repercussão geral, fixou as teses, em ata de julgamento publicada, de que "*[é] devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;"* e *"[o] valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição"*.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal está alinhavada no sentido de que "*[a] existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.*" (AI 795968 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023; e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

ARE 1298791 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022)

Em razão da responsabilidade solidária dos entes públicos réus, devem-se responsabilizados na proporção de 50% para cada um, a teor do artigo 87, *caput* e §2º, do CPC.

Sobre o parâmetro normativo a ser cominado, o Superior Tribunal de Justiça sufragou a orientação de que se aplicar o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, visto que "*[n]ão se pode concluir que a exigência da comprovação da hipossuficiência financeira, como requisito para o Poder Público fornecer gratuitamente a medicação prescrita ao autor, leve ao reconhecimento de um estimável proveito econômico"* e *"[a] obrigação de fazer imposta ao Estado, em tais casos, dá-se em caráter excepcional, somente se preenchidos todos os critérios estabelecidos no recurso repetitivo, sendo certo que as demandas dessa natureza objetivam a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.*" (AgInt no REsp n. 1.881.171/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 9/3/2021.) Igual sentido é a orientação do Eg. Tribunal de Justiça deste Estado:

> "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACOLHIMENTO – AÇÃO DE SAÚDE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DEVIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC – PRETENSÃO POSSUI VALOR INESTIMÁVEL, DECORRENTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM MODIFICAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. I – Os Embargos de Declaração têm como escopo esclarecer Sentenças ou Acórdãos que padeçam de vícios, como a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. II – Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer na qual a parte Autora pleiteia a condenação do Município ao custeio de procedimento médico do qual necessita e não tem condições financeiras de arcar. Malgrado tenha sido atribuído valor da causa com base no custo total do tratamento, é certo que a parte Autora não almejou o valor da prestação em si, mas sim a obrigação de fazer (tratamento da patologia), a qual possui valor inestimável, uma vez que decorre de direitos fundamentais, sendo inaplicável o disposto no §§ 3ª e 4º, III, do art. 85 do CPC. Nesta senda, aplica-se, então, a regra contida no art. 85, § 8º do CPC, que prevê a fixação dos honorários de forma equitativa. Precedentes deste TJMS. III – Levando em consideração a média complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo causídico, e tempo de tramitação do processo (mais de dois anos), tem-se como suficiente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para os honorários advocatícios. IV – Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com modificação parcial do julgado."
> (**TJMS**. Embargos de Declaração Cível n. 0815947-19.2021.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 11/05/2023, p: 15/05/2023)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.

Pela apreciação equitativa, deve-se fixar o valor dos honorários em R$ 2.000,00, na proporção de 50% para cada ente. No caso da sucumbência do Estado, o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

A presente sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Interposto(s) recurso(s) de apelação, intime(m)-se a(s) parte(s) adversa(s) para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal, consoante artigo 1.010, § 1º, do CPC. Manejado(s) recurso(s) de apelação na forma adesiva, intime(m)-se a(s) parte(s) adversa(s) para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal, na forma do artigo 1.010, § 2º, do CPC. Igualmente, suscitada alguma preliminar em contrarrazões, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, a teor do artigo 1.009, §§ 1º e 2º, do CPC. Observe-se eventual prazo em dobro, nos termos dos artigos 180, 183 e 186 do CPC.

Após os prazos de apelação e de contrarrazões, intime-se o Ministério Público para, querendo, apresentar apelação ou contrarrazões. Se apresentada apelação, intimem-se as partes adversas ara contrarrazões.

Apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, a teor do artigo 1.010, § 3º, do CPC. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e intimem-se as partes para, querendo, manifestar e requerer o que entender de direito. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das formalidades legais.

Publique-se Registre-se. Intimem-se.

Ribas do Rio Pardo, 24 de outubro de 2023.

Thiago Notari Bertoncello
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Endereço: Rua Waldemar Francisco da Silva, 1017, Nossa Senhora da Conceição I - CEP 79180-000,
Fone: (67) 3238-1242, Ribas do Rio Pardo-MS - E-mail: rrp-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NOTARI BERTONCELLO, liberado nos autos em 27/10/2023 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800218-90.2022.8.12.0041 e código M5nlbpyt.